InDret

Just pay it

La transacción de Kasky v. Nike

Antoni Rubí Puig
Facultad de Derecho
Universitat Pompeu Fabra

Working Paper nº: 171
Barcelona, octubre de 2003
www.indret.com

El último número de InDret ya informó mediante un link de la resolución por la *U.S. Supreme Court* del que despuntaba como caso del año en materia de *Commercial Speech*: *Nike v. Kasky* (539 U.S. ___ (2003)). En aquella ocasión, motivos formales ayudaron al Tribunal Supremo a no tener que entrar a resolver el caso. Ahora, las partes en litigio han anunciado la transacción del pleito y han descargado tanto al tribunal de instancia como, en caso de un nuevo recurso, al Tribunal Supremo del deber de pronunciarse sobre el fondo del asunto.

1. Hechos

Entre octubre de 1996 y diciembre de 1997 aparecieron reportajes en televisión y en prensa denunciando que los trabajadores de las fábricas de ropa y calzado deportivos que «Nike, Inc.» poseía en China, Vietnam e Indonesia recibían un sueldo inferior al salario mínimo de aquellos países, trabajaban más horas de las legalmente permitidas y sufrían abusos físicos y verbales e incluso sexuales en condiciones mínimas de salubridad y salud laboral. Para contrarrestar los efectos que estas informaciones pudieran tener sobre las ventas, algunos directivos de «Nike, Inc.» realizaron un comunicado de prensa y publicaron anuncios a toda página en los principales periódicos norteamericanos, en los que negaban los hechos imputados.

> Los reportajes se acompañaban de extractos de un informe realizado por Andrew Young, un antiguo embajador de los EE.UU, y otros empleados de su empresa de consultoría GoodWorks International, quienes, tras la visita a 12 fábricas, concluyeron que no existía una situación continuada de abusos o malos tratos a los trabajadores. Muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos y grupos antiglobalización criticaron el informe al que calificaban cuanto menos de sesgado e interesado. Entre otras cosas, reprocharon al Sr. Young que sólo hubiera realizado una única visita por fábrica, de menos de 4 horas y con traductores aportados por la propia «Nike, Inc.», y que hubiera consultado muchas de las ONGs locales por teléfono y durante menos de 10 minutos.

Así las cosas, Mark Kasky, un activista antiglobalización y *entrepreneur* judicial californiano, consideró que las manifestaciones realizadas constituían publicidad falsa o engañosa y desleal contraria al Bussiness and Professions Code, §17200 et seq. (hoy §17000 et seq.) y §17500 et seq., por lo que demandó en interés general del Estado de California a la sociedad y a cinco de sus directivos y solicitó la cesación de las manifestaciones y una indemnización de daños. En la contestación a la demanda, «Nike, Inc.» y sus directivos alegaron que las expresiones realizadas no constituían publicidad comercial, sino informaciones públicas que, como las opiniones políticas, debían quedar plenamente protegidas por la Primera Enmienda a la Constitución Federal. En consecuencia, esta cuestión constitucional impedía entrar a conocer el fondo del asunto (*demurrer*).

2. Íter judicial

Tanto la *Superior Court* de San Francisco como la *Court of Appeals* de California desestimaron la demanda al dar por válidas las alegaciones de «Nike, Inc.» y sus directivos. La *Supreme Court* de

California estimó por una mayoría de 4 a 3 magistrados el recurso del Sr. Kasky contra la sentencia de apelación: resolvió que las afirmaciones de los directivos de Nike y sus anuncios constituían información comercial y que, por tanto, no merecían una protección constitucional tan plena como la que ostentan otro tipo de expresiones, mas no entró a analizar su carácter engañoso. Por su parte, los magistrados disidentes entendieron que las manifestaciones de «Nike, Inc.» proporcionaban información significativa en el debate público sobre la comercialización en Estados Unidos de productos fabricados a bajos costes laborales, por lo que merecían una protección plena.

En el recurso ante la *U.S. Supreme Court*, «Nike, Inc.» alegó que cualquier palabra pronunciada en nombre de «Nike, Inc.» por alguno de sus directivos para proteger la reputación de la marca no constituía siempre publicidad y, aún así, de acuerdo con la Primera Enmienda, no debía entenderse que ésta quedaba protegida por un estándar más relajado que el previsto para el *Public Discourse* —en contra de lo que viene entendiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los USA (veáse especialmente Robert POST, "The Constitutional Status of Commercial Speech", 48 *UCLA L. Rev.* 1 (2000)).

El Tribunal Supremo resolvió *per curiam* que nunca debió haber entrado a conocer el recurso de «Nike, Inc.».

El voto particular (*concurring*) del magistrado John Paul Stevens explicó las razones formales:

a) La sentencia de la *Supreme Court* de California no era final en el sentido del 28 U.S.C. §1257, por cuanto quedaban cuestiones no resueltas, esto es, la posible calificación de la publicidad como engañosa o desleal.
b) Ninguna de las partes alegó que la jurisdicción competente fuera la federal.
c) El Tribunal Supremo no es un asistente judicial, por lo que no debe anticipar una cuestión de derecho constitucional antes de que se resuelva el fondo del asunto.

3. La transacción

En efecto, el Tribunal Supremo devolvió las actuaciones a la *Supreme Court* de California para que analizara si existió engaño o falsedad en las afirmaciones de «Nike, Inc.» y sus directivos y, en su caso, adoptara las consecuencias jurídicas derivadas de tal infracción. Mas ello ya no va a ser posible, puesto que el pasado 12 de septiembre las partes en litigio, «Nike, Inc.» y Mark Kasky, anunciaron la transacción de la controversia.

Mediante la transacción, «Nike Inc.» se compromete a entregar 1.500.000 $ a Fair Labor Association, una organización sin ánimo de lucro compuesta por 12 multinacionales fabricantes de ropa y calzado deportivos y titulares de marcas reputadas (entre ellas, "Reebok®", "Adidas®" y la propia "Nike®"), 175 universidades y diversas organizaciones no gubernamentales con el objetivo de promover la adhesión de las referidas sociedades a unos determinados estándares laborales y la mejora de las condiciones de trabajo en todos sus centros.

Los fondos se destinarán durante los próximos tres años a:

— La realización de obras en los locales de la asociación y la preparación de sus miembros para mejorar la calidad de un control independiente de las condiciones laborales en las fábricas,
— La colaboración entre las compañías implicadas para alcanzar un estándar laboral común y un único informe sobre responsabilidad social corporativa, y
— La adopción de programas de desarrollo laboral centrados en la educación y las posibilidades económicas de los trabajadores.

Además, «Nike Inc.» se obliga a continuar desarrollando en sus instalaciones el programa de educación a trabajadores y a mantener su programa de microcréditos por un total de 500.000 $ durante los dos años siguientes.

4. Críticos de la transacción

La transacción ya ha sido criticada en diversos foros: en primer lugar, se ha dicho que impide una solución jurisprudencial a un problema central de la doctrina del *Commercial Speech*, esto es, la delimitación del ámbito de protección de la libertad de expresión en el ámbito de la publicidad; y en segundo lugar, se ha afirmado que el hecho de que «Nike, Inc.» haya transigido el caso supone aceptar su derrota en el pleito (véase, por ejemplo, Ken PAULSON, "Free Speech may prove costly for corporations", First Amendment Center, septiembre 2003)

1) La primera crítica, que se añade a la ya formulada a la *U.S. Supreme Court* por no haber entrado a conocer del caso por motivos formales, parte de una concepción de la jurisprudencia entendida como bien público, en cuanto contribuye al desarrollo del derecho. La transacción, dicen, impide una nueva pieza en el conjunto de precedentes del Tribunal Supremo, lo que mina el avance de la doctrina del *Commercial Speech.* La crítica es punto menos que insostenible: "las transacciones, como cualesquiera otros contratos también acaban por crear nuevo derecho: articulan nuevos modos de relaciones sociales, estereotipan cláusulas que acaban por generar prácticas, costumbres o normas sociales que finalmente son tenidas en cuenta por el sistema formal de normas cuando no son incorporadas a él. [...] En derecho privado, el proceso es el último remedio, no el único (Pablo SALVADOR, "ABC de la Transacción", *InDret* 4/2002, p. 19). De entrada, no debe importar que el Tribunal Supremo no se pronunciara en su día ni que, por obra de la transacción, haya perdido una oportunidad para decidir si la reacción de «Nike, Inc.» constituye una forma de publicidad, y por tanto, es susceptible de ser ilícita por engañosa (de acuerdo con el estándar de protección mantenido en la actualidad). Más importante es que el Sr. Kasky movió pieza y catalizó el progreso de la doctrina del *Commercial Speech*. La falta de una resolución jurisdiccional que se sume al embrollo doctrinal actual en la materia no da fe de la falta de derecho: el derecho se mide por sus consecuencias y no por sus discursos.

2) La segunda crítica sigue este camino, pero lleva demasiado lejos las consecuencias de la transacción: la secuela del *settlement*, se dice, supone un menoscabo a la libertad de expresión de las empresas, que a la larga resultará en la abstención de las compañías a participar en debates públicos que puedan tener alguna relación con sus productos.

Concluir que será imposible para las empresas defenderse sin ninguna traba ante acusaciones relacionadas con sus productos es precipitado. En ningún momento se ha afirmado la ilicitud de las declaraciones de «Nike, Inc.» y sus directivos y ello por alguna de las tres consideraciones siguientes:

a) Tales declaraciones no constituyen publicidad, por lo que se les debe otorgar el estándar de protección concedido a las opiniones políticas y artísticas (véase, en este sentido, el voto particular del magistrado J. CHIN a la sentencia de la *Supreme Court* de California en el caso).

b) La defensa de «Nike, Inc.» constituye una forma de publicidad —o si se prefiere, un discurso comercial—, aunque no hay motivos suficientes para que no prevalezca ante otros intereses, en concreto, la represión del engaño. Así, el caso guardaría similitudes con la protección de la publicidad de tono político, ofensivo o provocador (cuyo ejemplo más socorrido son las campañas de Benetton (BVerfG 12.12.00 (1762/95; 1 BvR 1787/95) y (BVerfG 11.3.03 (1 BvR 426/02))). En este sentido, véase, por ejemplo, el comentario del prof. Ronald K. COLLINS, "Let Nike Talk", reproducido en la blog del profesor Eugene VOLOKH, The Volokh Conspirancy, en el que propone el concepto de daño como delimitador del ámbito de protección del *Commercial Speech*: así cabe otorgar menor protección a un anuncio que alaba la seguridad de un producto que a uno que apunta la necesidad de un modo de fabricación ecológico. En definitiva, sin que exista un riesgo de daño, no cabe rebajar el estándar de protección (pero, véanse el *amicus brief* presentado por el fondo de inversión Domini Social Investments LLC y otros, en el que se denuncia la posibilidad de daño a los accionistas; y Robert H. SITKOFF, "Corporate Speech and Citizenship: Corporate Political Speech, Political Extortion, and the Competition for Corporate Carters", 69 *U. Chi. L.R.* 1103, 2002).

c) Las declaraciones de «Nike, Inc.» y sus directivos constituyen claramente publicidad e incluso pueden considerarse engañosas, pero deben protegerse como cualquier otra forma de expresión, ya sea por consideraciones antipaternalistas, porque no hay motivos históricos o razones analíticas para distinguirlo de otras formas de discurso o porque el mercado dispone de mecanismos suficientes para afrontar el engaño. Véanse, entre otros, los trabajos de Ronald COASE, "Advertising and Free Speech", 6 *Journal of Legal Studies* 1, 7 (1977), Daniel FARBER, "Commercial Speech and First Amendment Theory", 74 *NW. U. L. Rev.* 372 (1979): Martin H. REDISH, "The Value of Free Speech", 130 *U. Pa. L. Rev.* 591, 635 (1982), Alex KOZINSKI/Stuart BANNER, "Who's afraid of Commercial Speech", 76 *Va. L. Rev.* 627 (1990), y Rodney A. SMOLLA, "Information, Imagery, and the First Amendment: A Case for Expansive Protection of Commercial Speech", 71 *Tex. L. Rev.* 777 (1993), Kathleen M. SULLIVAN, "Cheap Spirits, Cigarettes and Free Speech: The implications of 44 Liquormart, *Sup. Ct. Rev* 123 (1996), y, sobre todo, el voto particular (*concurring*) del magistrado Thomas a la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano en *44 Liquormart, Inc., et al. v. Rhode Island et al.*, (517 U.S. 484 (1996)).

La crítica también resulta excesiva por ignorar la finalidad principal de la transacción en el caso. Si «Nike, Inc.» accedió a la transacción fue como medio de ahorro de costes: el *settlement* pone fin a las costas de un proceso iniciado hace 7 años y ahorra las de continuar con el litigio, que más tarde que pronto podría llegar de nuevo al Tribunal Supremo,

multiplicando los gastos en defensa y asesoramiento jurídicos, sin perspectivas claras de éxito. En este sentido, es preciso recordar que entre los profesionales contratados para defender el pleito ante el Tribunal Supremo se contaba al Profesor Lawrence TRIBE, uno de los más sino el más distinguido catedrático norteamericano de derecho constitucional, y conocidas *Law Firms* cuyos honorarios deben de correr paralelos a su reputación. En definitiva, presumir que la transacción supone una restricción del ámbito de protección del *Commercial Speech* es exagerado: no es más que un pago actual para evitar otros mayores en el futuro.